

1500181-53.2020.8.26.0574

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

Comarca: Cerqueira César

Foro: Foro de Cerqueira César

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... o uso, fato comum em ocorrências de tráfico de drogas. Considerando-se que o tráfico ilícito de drogas é crime permanente, verifica-se permitido pela Carta Magna a ação dos agentes em revistas pessoais de pessoas suspeitas, em locais públicos ou privados, com vistas às providências necessárias e cabíveis para a prisão em flagrante do agente criminoso e consequente apreensão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cerqueira César

Foro de Cerqueira César

1ª Vara

Rua Olímpio Pavan, 355, Cerqueira Cesar-SP - cep 18760-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500181-53.2020.8.26.0574 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500181-53.2020.8.26.0574

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2206727/2020 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 13135258 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2124/20/129

- DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2206727 - DEL.POL.AGUAS DE S. BARBARA, 2124/20/129 -

DEL.POL.AGUAS DE S. BARBARA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

ELAINE CRISTINE GOMES DA FONSECA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

VISTOS.

ELAINE CRISTINE GOMES DA FONSECA, já qualificada nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções dos artigos 33, "caput", da Lei 11.343/06, sob a acusação de que, no dia 21 de agosto de 2020, por volta das 18h20min, na Estrada Vicinal Antonio Rossetti, na altura do KM 6, na cidade de Águas de Santa Bárbara, nesta comarca de Cerqueira César/SP, trazia consigo 50 (cinquenta) porções de cocaína, com peso líquido de 38,880 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de mercancia e entrega a terceiros, drogas essas que determinam dependência física e psíquica (cf. Auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, fotografias de fls. 13/18, laudos de exame químico-toxicológicos de fls. 20/23 e 84/86).

Auto de prisão em flagrante e demais peças do inquérito policial a fls. 01/45. Por decisão proferida em 22 de agosto de 2020, foi concedida a liberdade provisória com

medidas cautelares (fls. 63/65). Alvará de soltura cumprido a fls.79/80. A ré ofereceu Defesa Prévia a fls. 276/278. Foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 284/285). Não sendo o caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 11 de janeiro de 2021 (fls.289). Em audiência, foi inquirida 02 testemunhas de acusação e a ré interrogada (fls. 417 e 476/477 - gravações audiovisuais).

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia (fls.476/477). A douta Defesa, por sua vez, requereu a absolvição da acusada por insuficiência probatória, subsidiariamente, em caso de condenação pela aplicação do §4º, do art. 33 da Lei de Drogas, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal e do regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o direito de apelar em liberdade (fls. 481/491).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Segundo a inicial acusatória ", na data e local dos fatos, a denunciada trazia consigo, no interior do bolso dianteiro de sua jaqueta, as drogas acima descritas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de mercancia e entrega a terceiros, quando foi surpreendido por policiais militares. Na ocasião, policiais militares realizavam patrulhamento, quando abordaram o automóvel Fiat/Uno Mille Fire, placas AJY3125, anos 2001/2002, com três ocupantes, em revista pessoal no motorista, Gleiciano Aparecido Alves Santos e no passageiro do banco traseiro, Cleidiano Alves Santos, nada de ilícito foi encontrado. A seguir, os policiais militares indagaram acerca dos dados pessoais da passageira Elaine Cristine Gomes da Fonseca, ora denunciada, que ocupava o banco dianteiro ao lado do motorista, momento em que, Gleiciano, motorista do veículo, fugiu, adentrando num canavial e não sendo possível persegui-lo. Ato contínuo, foi verificado que a acusada apresentava um volume no bolso dianteiro da jaqueta, e após verificação constatou-se que a denunciada trazia consigo, 50 (cinquenta) porções de Cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e/ou regulamentar, para fins de mercancia e entrega a terceiros. Anote-se que a natureza e a quantidade da substância apreendida 50 (cinquenta) porções de Cocaína, com peso líquido de 38,880 gramas e as demais circunstâncias do caso apontam, nos termos do artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/06, que os entorpecentes se destinavam ao comércio ilícito ."

De prêmio, afasto a alegação de nulidade de provas alegada pela Defesa. Com efeito, extrai-se do conjunto probatório que a diligência dos policiais militares de abordagem e revista pessoal da acusada, com consequente prisão em flagrante delito pela posse de drogas ilícitas destinadas à mercancia espúria, ocorreu de modo regular, restou claro que a abordagem foi motivada pela atitude suspeita dos ocupantes do veículo, inexistindo, a despeito do entendimento da defesa, qualquer violação ao disposto no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal. Segundo os relatos, os policiais, durante patrulhamento de rotina, visualizaram os ocupantes do veículo demonstrarem nervosismo exacerbado, circunstância que ensejou a abordagem. Ademais, foi apreendida significativa quantidade de entorpecente com a acusada, embalada e acondicionada em forma incompatível com o uso, fato comum em ocorrências de tráfico de drogas. Considerando-se que o tráfico ilícito de drogas é crime permanente, verifica-se permitido pela Carta Magna a ação dos agentes em revistas pessoais de pessoas suspeitas, em locais públicos ou privados, com vistas às providências necessárias e cabíveis para a prisão em flagrante do agente criminoso e consequente apreensão do material ilícito, desde que presente a justa causa. Inquestionável que a ação dos agentes da lei se revestiu de fundada suspeita, em conformidade com o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, sendo descabida a aventada ilegalidade da busca pessoal.

Nesse sentido:

"TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. REVISTA REALIZADA ANTE A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O ACUSADO ESTAVA NA POSSE DE OBJETOS ILÍCITOS. EIVA INEXISTENTE. 1. Nos termos dos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a revista pessoal independe de mandado quando se está

diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos. (...)" (STJ Habeas Corpus nº 552.395-SP, Quinta Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, j. 20.02.2020)."

No mérito, à luz da prova produzida, a denúncia procede integralmente.

A materialidade delitiva restou configurada pelo auto de prisão em flagrante a fls. 01/02, boletim de ocorrência a fls. 08/10, auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), fotografias (fls. 13/18), laudo de constatação provisória a fls. 20/23, laudo toxicológico a fls. 84/86, laudo pericial do celular (fls. 124/171), bem como por toda a prova oral produzida em juízo.

A autoria delitiva, de igual modo, também restou inconteste e recai sobre a ré.

A testemunha Rodolfo Filadelfo, policial militar, aduziu "que estavam em patrulhamento, quando visualizaram um veículo passando, na pista que liga Manduri a Águas. Os ocupantes olharam e ficaram com atitude receosa. Seguiram na pista e foram atrás, sendo que a todo momento eles olhavam para trás. Resolveram abordar o veículo, desceram os três indivíduos: o motorista, a Elaine (banco da frente) e outro no banco de trás. Relizaram a revista pessoal, com o motorista não encontraram nada, quando chegaram próximo da Elaine, o motorista saiu correndo, por isso algemaram os dois. Visualizaram que no bolso da Elaine tinha um volume. No momento em que foram revistar a Elaine tinha um invólucro de plástico. A ré disse, inicialmente, que era droga para uso pessoal. O rapaz, entretanto, falou que era do irmão e que iriam entregar em Águas de Santa Bárbara. Colocaram ambos no veículos e conduziram até Avaré. A Elaine falou que era para consumo próprio e que a droga era dela. A acusada tinha consciência que estava com a droga no bolso. Fizeram buscas no veículo e nada de ilícito foi encontrado pelo que recorda. O veículo não tinha adaptação ou fundo falso. Relatou que a fundada suspeita adveio da forma de olhar das pessoas que estavam no veículo. Acreditaram que poderia ser uma infração de trânsito. Não conhecia os integrantes do veículo. Consegue afirmar com certeza que o motorista era o Cleidiano. Disse que foi o seu parceiro que verificou o volume no bolso dela. Não foi feita uma revista, apenas pegaram o que tinha em seu bolso. Relatou que saiu com a viatura da entrada do Vale das Águas, onde fazem patrulhamento por ser área rural de competência. Visualizaram o carro na estrada e a abordagem foi na pista, não sabe recordar exatamente a distância, mas acredita que uns 2 quilômetros."

O policial militar, Adriano Ferruci disse "que no dia em questão estava em serviço em Santa Bárbara; fazia patrulhamento na estrada rural. Abordaram um fiat Uno de cor branca, onde estavam essas pessoas. Fez a busca pessoal no motorista e eram três pessoas, dois homens e uma mulher. Realizou a busca no motorista e no passageiro e nada de ilícito foi encontrado. No momento em que foi fazer a entrevista com a Elaine, um dos homens saiu correndo, atravessou o asfalto e entrou no matagal, ficou sem entender o que tinha acontecido. Colocaram algema nos dois, em razão da fuga. Voltou para fazer a entrevista na Elaine e quando colocou a algema percebeu que um dos bolsos estava mais avantajado. Realizou a vistoria no bolso em questão, e ela trazia um saco plástico com bastante cocaína. Questionada a ré disse que é usuária e que a droga seria dela para uso. A acusada disse que não poderia ser presa, e falou que viu na televisão que mulher com criança pequena não poderia ser presa por crime de tráfico. Em entrevista com o outro rapaz que estava no carro, sem falar que tinha encontrado a droga, perguntou para ele se sabia o que tinha; de pronto respondeu "aquela cocaína lá é do meu irmão, do Gleiciano". O depoente perguntou o que ia fazer, e Cleidiano respondeu que o irmão tinha pego para entregar em outro local, recebendo dinheiro para isso. Nesse momento, voltou com a Elaine e perguntou se ela era usuária mesmo, e esta respondeu afirmativamente. Indagou como era possível ela, dizendo que era gestante, usar 50 (cinquenta) papéletes, e ela não respondeu nada. Acrescentou que se uma gestante usar tudo isso, a probabilidade de matar o feto é muito grande. Elaine só ficou na delegacia, sendo liberada na custódia e até onde sabe ela nunca retornou para a prisão. Informou que não era evidente a gravidez, ela que falou. No patrulhamento, notou que o motorista olhou por algumas vezes no retrovisor, para ver onde estava a viatura; o passageiro que estava no banco de trás também olhou algumas vezes, o que levou à abordagem. Disse que não tinha escurecido ainda, estava próximo de

escurecer. Nunca pegou usuários de drogas com tanta quantidade de drogas, disse que o usuário normalmente é uma porção, um cigarro, um pino. Relatou que as embalagens estavam a vácuo, o que não é comum para a região. O carro foi vistoriado e nada de ilícito sendo encontrado. Não havia fundo falso ou outra coisa de ilícito. Era um fiat Uno, carro de passageiro para transporte de pessoas. Não houve perseguição ao veículo, somente foi usado o sinal luminoso e sonoro para a parada. Eles estavam em sentido a Santa Bárbara. Não se recorda a posição do sol naquele momento, era um fim de tarde; conseguia visualizar no retrovisor. O depoente quem fez busca na ré, foi feita a revista no bolso externo de um casaco que ela estava usando, somente nesse bolso, que foi realizada a vistoria. Foi o depoente quem tirou o conteúdo do bolso. Disse que não fez mais nenhuma busca na Elaine, fez apenas no casaco e uma vistoria na bolsa que estava no carro. Em Águas de Santa Bárbara, na data, não havia policial feminina."

A ré Elaine Cristine Gomes da Fonseca, negou a prática delitiva. "negou que estivesse com as drogas, disse que não viu a polícia localizar os entorpecentes. Relatou que na delegacia preferiu ficar em silêncio. Disse que não é usuária de drogas. Relatou que somente pegou a carona e ajudou com o valor de R\$50,00 para o combustível, mas não conhecia as pessoas. Posteriormente, disse Cleidiano estava junto no carro. Relatou que mora com Cleidiano e que Gleiciano é irmão dele."

Com efeito, verifico que as versão ofertada pela ré não encontra respaldo nas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não passam de uma tentativa infrutífera de eximi-la da grave imputação que lhes é feita, o que é plenamente lícito, mas insuficiente para desfigurar a tese acusatória que vem amparada pelo depoimento dos policiais e prova da materialidade. Ademais, da fase inquisitiva à judicial, os depoimentos prestados pelos agentes foram firmes e seguros, não se vislumbrando qualquer interesse em acusar ou prejudicar a ré, merecendo plena credibilidade a versão por eles ofertada. Não se pode conceber a justificativa rasa de que os policiais permanecem perseguindo cidadãos e atribuindo-lhes a propriedade de quantia tão grande de entorpecente com o único fim de prejudicar a ré. Nesse sentido:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846) (g.n.).

Assim, as provas colhidas em juízo apontam para a ilícita mercancia praticada pela ré. A tipificação do crime de tráfico de drogas, in casu, extrai-se das circunstâncias da prisão, da quantidade de drogas apreendidas 50 (cinquenta) porções de cocaína (peso líquido 38,880 gramas), do modo pelo qual estava acondicionada (embaladas à vácuo) e mensagens no aparelho celular (fls. 124/171). De mais a mais, ressalto que para caracterização do crime de tráfico de drogas não é indispensável que o agente seja flagrado realizando o comércio de drogas. O tipo penal do art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006 é de conteúdo múltiplo e define crime de perigo abstrato. Nesse sentido:

"... não é indispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, bastando o conjunto de indícios e presunções que, saliente-se, são claros e convergem contra o acusado, não podendo o juiz desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas, representando aquelas o conhecimento adquirido pela prática e observação do cotidiano." (TJSP, Apelação n. 0019906-40.2012.8.26.0071, rel. Julio Caio Farto Salles, j. 11/12/2014) (g.n.).

De outra feita, a defesa não explicou e não logrou refutar as assertivas minuciosas dos depoentes. Não indicou motivos concretos e plausíveis para falsa incriminação. Assim, o contexto fático revela, de maneira indubitosa, que a ré praticava o

comércio de entorpecente, sendo de rigor a condenação.

Diante do exposto, por esses fundamentos e mais o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO a ré ELIANE CRISTINE GOMES DA FONSECA, já qualificada nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Resta dosar a pena pelo critério trifásico adotado pelo Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria da pena, atento aos elementos preconizados pelo artigo 42 da Lei 11.343/06 c.c. 59 do Código Penal, verifico que o réu é primário (F.A. e certidões a fls.237/239), razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica da ré (CP, arts. 49 e 60). Na segunda fase, ausentes quaisquer das circunstâncias agravantes ou atenuantes, portanto, mantenho a pena anteriormene aplicada. Na terceira fase, não há causas de aumento. Por outro lado, entendo que se faz necessário o reconhecimento da diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois a ré é primária e não há nos autos notícias de sua participação em associação criminosa ou de que esteja presente a habitualidade delitiva. Assim, diminuo a pena anteriormente imposta em 2/3 (dois terços) resultando em 01 (um) ano, 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Não estão presentes mais causas de aumento ou de diminuição da pena. Portanto, fixo em definitivo a pena a cumprir de 01 (UM) ANO, 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA , COM O DIA UNITÁRIO NO PISO MÍNIMO LEGAL.

Pese contrário ao entendimento deste Magistrado, necessário apontar que o regime inicial deverá ser o ABERTO, conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exarado no bojo do HC n. 596603-SP, no qual houve determinação para imposição de regime inicial aberto para cumprimento de pena, inclusive em relação a fatos futuros, na hipótese de condenação por tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal. Confirma-se (...) Aos condenados que atualmente cumprem pena e aos que vierem a ser sancionados por prática do crime de tráfico privilegiado, determinar que não se imponha - devendo haver pronta correção aos já sentenciados - o regime inicial fechado de cumprimento da pena. (STJ - HC: 596603 SP 2020/0170612-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04/08/2020). Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal - HC 118.533 - reconheceu que o delito em questão não é mais hediondo, entendo viável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Desta forma, faço a substituição da pena privativa de liberdade anteriormente fixada por duas restritivas de direitos. Assim sendo, observado o disposto pelo artigo 44, parágrafo 2º, 2ª parte e na forma dos artigos 45, parágrafo 1º e 46, todos do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, a de Prestações de Serviços à Comunidade e de Prestação Pecuniária, por se revelarem as mais adequadas ao caso, sendo aquela consistente em tarefas gratuitas a serem desenvolvidas, pelo prazo da condenação, junto a entidade determinada pelo juízo da execução, devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado, sem prejuízo da multa já fixada e a prestação pecuniária no valor de um terço do salário mínimo nacional da época da infração penal, sendo destinada para entidade beneficente também indicada pelo juízo das execuções penais.

Ao Juízo da Execução, após o trânsito em julgado desta decisão, caberá fiscalizar a entidade beneficiada com a prestação de serviços, a qual deverá ser comunicada a respeito, através de seu Representante, com remessa de cópia da presente sentença, incumbindo-lhe encaminhar mensalmente relatório circunstanciado, bem como a qualquer tempo, comunicar sobre a ausência ou falta disciplinar da condenada, consoante disposto pelo artigo 150 da Lei nº 7.210/84. Deverá, ainda, ser cientificado que a condenada é facultada cumprir a pena substitutiva em menor tempo (artigo 55 do Código Penal), sendo que, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada ou restante.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva (artigo 312 do CPP), a ré poderá apelar

em liberdade.

Conforme art. 63 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 91 do CP, decreto o perdimento de tudo quanto apreendido neste processo. Não tendo havido controvérsia, no curso do processo, sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente (Lei n. 11.343/06, arts. 33, §§ 1º e 2º, e 58, §1º), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, preservando-se fração suficiente para eventual contraprova. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente, caso isso ainda não tenha sido providenciado.

Após o trânsito em julgado desta decisão, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação, para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição da República, oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação da ré, e providencie-se o necessário para o cumprimento da sanção penal imposta. Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias e efetuem-se as averbações de praxe (NSCGJ, Cap. V, itens 22, d, e 23). Custas processuais nos termos da lei.

P.I.C.

Cerqueira Cesar, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA